



**Unidad Administrativa Especial Agencia del
Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales -ITRC**

FUNDAMENTO PARA PROFERIR FALLO ABSOLUTORIO – No hay mérito para sancionar

Incremento patrimonial no justificado, entre el 1 de enero de 2005 y el 30 de septiembre de 2008, el cual fue evidenciado tanto en sus cuentas bancarias, por valor de \$14.751.932, como en el nivel de gastos e inversiones realizadas por valor total de \$13.665.064.81.

La disciplinada fue absuelta debido a que una vez analizado bajo los presupuestos de la sana critica todo el material probatorio allegado a lo largo de la instrucción, tanto en su fase previa como en la posterior etapa de formulación de cargos, incluyendo en las manifestaciones de la defensa, no encontró el despacho mérito para proferir en contra del disciplinado decisión sancionatoria por las diferencias encontradas en el análisis de recursos frente a gastos, inversiones y disminución de pasivos para el periodo reprochado.

FUENTE FORMAL –LEY 734 DE 2002, art. 9 Y 170

Dependencia:	Subdirección de Investigaciones Disciplinarias
Número de proceso:	1704-01-2012-151
Número y fecha del fallo:	17413-01, del 11 de octubre de 2012
Asunto:	Fallo de Primera Instancia
Criterio de Selección:	Fallo absolutorio

OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO

Se procede a proferir fallo de primera instancia dentro del expediente administrativo disciplinario No. 1704-01-20012-01, seguido en contra de (XXXX).

CARGO FORMULADO

Una vez concluida la investigación disciplinaria tramitada en el proceso administrativo disciplinario número 1704-01-2012-151, la Subdirectora Técnica de Investigaciones Disciplinarias de la Agencia ITRC, procede a proferir fallo de primera instancia, conforme a las exigencias del artículo 170 de la Ley 734 de 2002 y de acuerdo a lo que sigue.

Cargo

"(...)XXXX presuntamente obtuvo, durante los años 2006, 2007 y 2008 un incremento patrimonial hasta el momento no justificado, ya que como resultado del Análisis de Ingresos vs. Gastos (véanse hojas 17 y 18), se estableció que sus gastos e inversiones realizados durante el citado período, fueron superiores a sus ingresos debidamente probados, así: para el año 2007 por valor de \$4,745,708 , y para el año 2008 por valor de \$8,919,356, y como resultado del Análisis financiero (véanse hojas 18 y 19), se estableció que en las cuentas de ahorros Nos. 0160-009602xx y 0160-6001-08xx del Banco Davivienda, las cuales aparecen a su nombre, fueron depositadas sumas de dinero superiores a sus ingresos percibidos como funcionario de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, así: para el año 2006 en cuantía de 6 600.000; para el año 2007 por un valor de 7 487.300 y para el año 2008 por una suma de 664.632, sumas que deberá justificar."

CONSIDERACIONES DE INSTANCIA

CASO CONCRETO

Centrado en las diferencias que fueron objeto de reproche, en primer lugar, el Despacho se ocupará de tratar las relacionadas con INGRESOS Vs GASTOS.

En este sentido se relacionará la explicación dada por la defensa para luego efectuar el análisis probatorio correspondiente.

I - Con relación a las consignaciones en el año 2007, a la cuenta del encartado por las sumas de \$150.000 el 3 de febrero, \$93.000 y \$57.000, en febrero y \$38.000 y \$112.000 el 14 de abril, se dijo que éstas fueron realizadas por el señor XXXX (hermano del investigado), por concepto de abonos del préstamo que el señor XXXX le realizara para el pago de la matrícula universitaria.

A partir de lo anterior, se hizo necesario oír en declaración juramentada al señor XXXX, quien el 3 de octubre de 2011, afirmó ser hermano del señor XXXX, a la vez que anotó que su núcleo familiar en el período en estudio estaba conformado por él y por su mamá XXX; manifestó que trabajaba como Coordinador de mantenimiento y que sus ingresos mensuales eran de menos de UN MILLÓN DE PESOS (\$1.000.000); dijo que para los años 2006 a 2008, estudiaba Ingeniería Mecánica; además indicó que recibió algunos préstamos de su hermano, para el pago de la Universidad, razón por la cual le realizó consignaciones; en punto a ello, aclaró que dichos depósitos eran efectuados directamente por él, desde la ciudad de Bogotá, en la Oficina Las Ferias; acotó que en alguna oportunidad consignó cheques, los cuales eran recibidos por concepto de subsidio familiar, habida consideración que su señora madre era mayor de 60 años.

Finalmente anexó a la diligencia 14 copias de consignaciones realizadas a la cuenta del disciplinado y 2 autorizaciones de pagos del 22 de diciembre de 2005 y 10 de julio de 2006, expedidos por la Universidad Central, entre las cuales están las consignaciones antes referenciadas.

Continuación de acta de audiencia del fallo en primera instancia dentro del expediente 1704-01-2012-151

Revisada la información allegada al proceso por el señor XXXX, se pudo verificar que si bien es cierto no se registra el nombre del depositante en los recibos de consignación, también lo es, que a partir de la constatación de los extractos bancarios, logró establecerse que estas fueron realizadas desde la ciudad de Bogotá y en su mayoría desde la sucursal Las Ferias; también se observan dos consignaciones en cuatro cheques por valor de \$19.000 cada uno; transacciones que coinciden con lo afirmado por el declarante y por el investigado en diligencia de versión libre vista a folios 1254 a 1256; conforme con lo anterior, este Despacho debe aceptar los argumentos expuestos por la defensa y en tal sentido incluirá en el Análisis de Ingresos Vs. Gastos, como un Ingreso, en el rubro Devolución préstamos señor XXX, la suma de \$450.000,00 para el año 2007.

- Respecto de la venta del automóvil Swift en el año 2007, por valor de \$11.000.000: En torno a la propiedad del vehículo antes referido, en el proceso disciplinario se conoció lo siguiente:

Dentro del FORMULARIO UNICO DE DECLARACIÓN JURAMENTADA DE BIENES Y RENTAS Y ACTIVIDAD ECONÓMICA PRIVADA que contiene la información patrimonial del disciplinado presentada en los años 2005 a 2008, se relacionó dentro de sus propiedades, el vehículo de placas QYA-049:

Según lo reportado se encuentra que la Declaración correspondiente a los bienes poseídos en el año 2006 (presentada al año siguiente), fue la última que reportó el automotor en comento, toda vez que a partir del año siguiente se relacionó un nuevo vehículo.

Ahora bien, con Oficio No. UL 00121295, del 24 de febrero de 2010, la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal de Santiago de Cali, informó que el investigado figura como propietario desde el 7/04/1999 del vehículo Chevrolet Swift, Modelo 1991 de placas XXX, sin que se registre traspaso o movimiento posterior alguno.¹²

Sin embargo debe señalarse que en el plenario obra copia autenticada del contrato que da cuenta de la venta del mencionado vehículo, el cual se identifica con el No. XXX, suscrito el 3 de junio de 2007, por el señor XXX, en calidad de vendedor, y el señor XXX, en calidad de comprador, por valor de ONCE MILLONES DE PESOS (\$11.000.000,00), cancelando DIEZ MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS (\$10.700.000,00), a la fecha de la firma del contrato de venta, y TRESCIENTOS MIL PESOS (\$300.000,00), a la firma del traspaso.

De este modo, si bien el traspaso del vehículo no fue realizado, no puede este Despacho en esta instancia restarle credibilidad al negocio acordado entre las partes, máxime cuando el soporte del mismo se allegó al proceso y no fue controvertido; por lo anterior el tallador acepta el argumento expuesto por la defensa en cuanto tiene que ver con la venta del vehículo Chevrolet Swift de placas XXX, y en consecuencia el valor recibido, esto es, \$10.700.000, toda vez que el traspaso como pudo verificarse nunca fue realizado, se incluirá en el Análisis de Ingresos Vs. Gastos, como un Ingreso para el año 2007.

Continuación de acta de audiencia del fallo en primera instancia dentro del expediente 1704-01-2012-151

- En cuanto a los viáticos pagados por la DIAN, el 12 de septiembre de 2008, por valor de \$664.632[^]

La defensa adjuntó al escrito de descargos presentado, Comprobante de Egreso No. 1335 del 11 de septiembre de 2008, expedido por Ejecutor de Pagos de la Dirección Seccional de Impuestos de Cali, en el que se observa que mediante cheque del Banco de Bogotá se le pagó al investigado la suma de SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS (\$664.632,00) por concepto de viáticos por traslado a la ciudad de Bogotá.

En este sentido, amparados en el documento aportado, el cual no fue objetado ni descalificado a lo largo de la instrucción, debe entonces reconocerse que en el estado procesal actual resulta imposible desconocer su valor demostrativo y en consecuencia la suma bajo análisis será tenida en cuenta como un ingreso para el año 2008, dentro del Análisis de Ingresos Vs. Gastos.

Así mismo, debe indicarse que la misma suma fue cuestionada dentro del análisis financiero, por corresponder a una partida que depositada en la cuenta de ahorros No. 0160-0096020-9 que en el banco DAVIVIENDA está aperturada a su nombre, se desconocía su origen.

Sin embargo, a partir de la nueva información, ya decantada, debe decirse que a pesar que el comprobante de egreso da cuenta de un giro por título valor, mientras que el extracto bancario no precisa este tipo de transacción, no puede desconocerse que la fecha y el valor de la transacción, se corresponden con los registrados por el funcionario ejecutor de pagos XXX. En este sentido dando aplicación al artículo 9 de la Ley 734 de 2002, en cuanto al favorecimiento de la duda, la suma se tendrá por explicada.

- En lo referente a los ingresos obtenidos por concepto de venta de minutos a celular, correspondientes a las líneas Nos. 3113440701, 3113189488, 3154037985, 3164233441, 3164499034, 3148883244 y 3148883245.

Como prueba de la venta de minutos, la defensa allegó al plenario planillas con la relación de la venta de minutos durante los años 2006 a 2008, de las líneas celulares a nombre del señor XXX y a nombre de XXX, así como original de las facturas de las líneas a nombre del encartado, igualmente hace referencia a la certificación expedida por el Fondo de Empleados de la Dirección de Impuestos y Aduanas XXX Suroccidente, referente a la asignación de líneas telefónicas al investigado.

Sobre el particular, obra en el plenario Acta de Inspección Administrativa¹⁸ realizada el 16 de julio de 2010 al Establecimiento de Comercio de propiedad del acusado, denominado XXX, con Nit. XXX, ubicado en la Avenida XXX, en la cual se dejó sentado que en las mismas instalaciones funciona el establecimiento de comercio denominado SERICOM, de propiedad de la señora XXX, a quien el Despacho escuchó en declaración juramentada el 15 de julio de 2010 y en ampliación el 28 de septiembre de 2011, y a propósito de la cual manifestó en cuanto a los ingresos por venta de minutos a celular, que las líneas que se encuentran a nombre de ella

Continuación de acta de audiencia del fallo en primera instancia dentro del expediente 1704-01-2012-151

De lo anterior se tiene que al señor XXXX el Fondo de Empleados de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales FEDIAN Suroccidente, le desembolsó el 15 de julio de 2005 un crédito de libre inversión por cuantía de \$16.591.680; respecto del uso de este préstamo el investigado en diligencia de versión libre rendida el 16 de julio de 2010 afirmó que el dinero le fue entregado a la señora XXX, para la adquisición de un inmueble, y allegó documentos de la solicitud y desembolso del préstamo mencionado, en los cuales se puede observar que la cuota mensual era de \$421.320.

Lo anterior fue ratificado en declaración juramentada por la señora XXX, quien aseveró que en el año 2005 adquirió una casa por la suma de \$30.000.000, la cual se canceló con ahorros y un préstamo

Sobre el presente aspecto ya se había adelantado parte del análisis al referirse este Despacho a los ingresos recibidos por el disciplinado como pago del préstamo que le efectuó a su actual esposa con dineros obtenidos de FEDIAN; de igual forma, la señora XXX, en declaración juramentada rendida el 29 de septiembre de 2011 reconoció haber efectuado los depósitos cuestionados como devolución del pluricitado préstamo, anexando a la diligencia original de algunos comprobantes de consignación.

Adicionalmente, sobre el depósito realizado el 28 de mayo de 2007 por \$1.224.000, se estableció que fue un Abono por Transferencia de Fondo, el cual fue efectuado desde la cuenta de DAVIVIENDA No. XXX, a nombre de la señora XXX, de acuerdo con el extracto bancario que obra en el plenario a folio 1969, restando cualquier duda sobre su procedencia.

De este modo, no existiendo ningún motivo fundado que reste credibilidad al testimonio recepcionado y por el contrario existiendo material probatorio que permite dar por cierta la existencia de los negocios y su funcionamiento, las partidas se tendrán por justificadas.

Así las cosas, resueltas a su favor las diferencias encontradas en el Análisis de Ingresos Vs. Gastos para los años 2007 y 2008, como las consignaciones que le fueron reprochadas al investigado en el Pliego de Cargos No. 1018-14 del 27 de abril de 2011, este Despacho debe proceder a absolver al disciplinado del cargo contra él formulado, ya que se ha desvirtuado la existencia de la falta.

En mérito de lo expuesto, la Subdirectora Técnica de Investigaciones Disciplinarias de la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales,

RESUELVE:

PRIMERO: ABSOLVER DE RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA al señor XXXX, identificado con la cédula de ciudadanía No. XXX, por el cargo formulado en el Pliego de Cargos No. 1018-14 del 27 de abril de 2011, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente decisión, y en consecuencia **ARCHIVAR DEFINITIVAMENTE** la actuación.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión, de conformidad con lo establecido en los Artículos 101 y 107 de la Ley 734 de 2002, al apoderado, en su condición de defensor del investigado,

Continuación de acta de audiencia del fallo en primera instancia dentro del expediente 1704-01-2012-151

quien para tal efecto puede ser ubicado en la Carrera XXX de la ciudad de Cali - Valle del Cauca, de acuerdo con los registros que hizo en acta de notificación de personal del Auto por el cual se le corrió traslado para alegar de conclusión.

TERCERO: ADVERTIR que contra la presente decisión procede el **RECURSO DE APELACIÓN**, de acuerdo con lo previsto en los artículos 111, 112, y 115 de la Ley 734 de 2002.

CUARTO: En firme la presente providencia, **COMUNICAR** su sentido a la Procuraduría General de la Nación, para lo de su competencia.

QUINTO: Esta decisión rige a partir de su notificación.

CLARA NIEVES SILVA PEREZ
Subdirector Investigaciones Disciplinarias -ITRC
Director del Proceso

Proyectó: Sandra Patricia Cortés Sierra
Revisó: Gina Paola Cortés López